

1500087-75.2022.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... avaliada para aumentar a pena-base e, também, afastar o tráfico privilegiado:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIPO POR VIOLADO, QUANTO A UMA DAS TESES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. CONDENAÇÕES TRANSITADAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Ilhabela-SP - cep 11630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500087-75.2022.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500087-75.2022.8.26.0626

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033650/2022 - DEL.POL.ILHABELA, 22842575 - DEL.POL.ILHABELA, 303/22/302 - DEL.POL.ILHABELA, 2033650 - DEL.POL.ILHABELA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDUARDO KAICKY GARCIA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia EDUARDO KAICK GARCIA, como incurso na prática do delito tipificado no art. artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, da Lei 10.826/03, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 05 de fevereiro de 2022, às 13h30, na Rua João Evangelista da Silva, nº 19, bairro Reino, nesta cidade e comarca de Ilhabela, EDUARDO KAICKY GARCIA, (qualificado à fl. 18), trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 23 (vinte e três) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 2.377,68g, bem como,

792 (setecentos e noventa e duas) porções de cocaína, pesando aproximadamente 616,01g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/23, auto de constatação preliminar de fls. 25/26 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 74/76.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, EDUARDO KAICKY GARCIA, (qualificado à fl. 18), possuía 04 (quatro) cartuchos, calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, oportunidade em que, avistaram o denunciado, na presença de outras duas pessoas, que por sua vez, já possuía diversas delações anônimas o indicando como o responsável pelo tráfico de drogas. A abordagem foi realizada. Apurou-se ainda que, realizada busca pessoal, foi localizado consigo, um aparelho de telefone celular. Ato contínuo, os milicianos conseguiram localizar uma porção de maconha com Danilo Santos de Freitas, que, ao ser inquirido, confirmou que adquiriu diretamente do denunciado.

Informalmente indagado, EDUARDO confessou a prática dos fatos aos policiais militares, informando, em seguida, que guardava outras substâncias em sua residência.

Já na residência do denunciado, e após a entrada ser franqueada pela sua avó (proprietária), os policiais lograram êxito em localizar, na varanda do imóvel, uma mochila rosa, contendo em seu interior 288 (duzentas e oitenta e oito) porções de cocaína.

Não bastasse, os policiais ainda encontraram 11 (onze) porções de maconha, uma balança de precisão, anotações contábeis típicas do tráfico de drogas e sete cartuchos calibre .38, sendo que, três deles estavam deflagrados, no quarto de EDUARDO.

Outrossim, e considerando que as delações indicavam que o denunciado se valia de seu veículo e veículos abandonados na rua para o acondicionamento de entorpecentes, os policiais iniciaram buscas, sendo certo que, conseguiram localizar 10 (dez) porções de maconha e a quantia de R\$ 1.072,00, que estavam no interior do veículo Renault Clio, placas DBZ6h76, de sua propriedade.

Em continuidade, os policiais ainda conseguiram encontrar mais 02 (duas) porções de maconha e 504 (quinhentas e quatro) porções de cocaína, que estavam no interior do veículo VW Gol, sem placas.

Interrogado perante a Autoridade Policial, EDUARDO confessou parcialmente a prática dos fatos (fl. 18).

Denúncia recebida em 03 de abril de 2022 (fls. 141/146), sendo mantida a prisão preventiva do denunciado.

Citado, o acusado ofereceu Defesa Prévia, pleiteando pelo não recebimento da denúncia e pela produção de todos os meios de provas em direito admitidos.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e defesa. Por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia, com a condenação prevista na denúncia (fls. 225/231).

A Defesa, por sua vez, sustentou, como preliminar, a ilicitude das provas colhidas contra o acusado em razão da violação ao seu domicílio. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao delito previsto no art. 12, da lei 10.826, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto (fls. 240/255).

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fatos tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da lei 10.826, na forma do artigo 69, caput, do mesmo CODEX.

PRELIMINARMENTE

DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO

Cumprе salientar que, a despeito das alegações do acusado de que os policiais teriam ingressado em sua residência sem autorização e sem mandado judicial, tal

ingresso é válido e regular.

Vejam os.

O artigo 5º, XI, da Constituição de 1988, traz a proteção ao domicílio, tornando-o inviolável. Por domicílio, entende-se o espaço físico no qual o indivíduo goza de sua privacidade, nas suas mais variadas modalidades. Assim, o domicílio deverá ser entendido como qualquer compartimento habitado utilizada para moradia, profissão ou atividade. Por isso, escritórios, consultórios devem ser enquadrados no conceito de domicílio.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Portanto, durante o dia, é possível o ingresso em domicílio nas seguintes hipóteses: com o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou mediante determinação judicial. Durante a noite, o ingresso em domicílio alheio só pode ocorrer nos seguintes casos: com o consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. No caso dos autos, o policial militar ouvido em juízo asseverou que familiares do acusado franquearam o ingresso em sua residência, o que, por si só, já afasta qualquer alegação de indevida violação de domicílio.

Cumpra primeiramente salientar que, a despeito da negativa desse consentimento apresentada em audiência, o depoimento e palavras dos policiais militares gozam de especial credibilidade, sendo servidores públicos, aparentemente sem nenhum interesse ilegítimo em produzir provas fraudulentas ou até mesmo "perseguir" o acusado, seu depoimento, desde que corroborada pelas demais provas e elementos de informação, deve ser valorado com especial relevância.

Todavia, ainda que se pudesse colocar em xeque tal autorização dada pelo acusado, há outros diversos elementos de prova nos autos que dão sustentação à legitimidade do ingresso em seu domicílio.

Como acima transcrito, uma das hipóteses em que é permitido o ingresso em domicílio alheio são nas situações de flagrante delito. Ora, dos autos consta, inclusive fato esse confessado pelo próprio acusado, que em sua residência foram encontradas as substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 20/23), bem como outros petrechos comumente destinados ao tráfico de entorpecentes, como balança de precisão, anotações de contabilidade etc...

O crime de tráfico de drogas é peculiar, pois algumas de suas condutas correspondem a crimes permanentes, cuja consumação se prolonga no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento.

Dessa forma, quem, por exemplo, guarda ou tem em depósito determinada quantidade de droga em sua residência está continuamente em flagrante delito.

Considerando a exceção trazida pelo próprio dispositivo constitucional a respeito da inviolabilidade do domicílio, conclui-se que o armazenamento de drogas em determinada residência admite a entrada de agentes policiais independentemente de autorização judicial.

No caso dos autos, haviam fundadas suspeitas de que no interior da residência do acusado estaria ocorrendo o flagrante delito. Primeiramente, conforme relatado pelos policiais militares, havia denúncias anônimas dando conta de que o acusado praticava o tráfico de drogas o local, inclusive mencionando os veículos onde encontradas parte das substâncias apreendidas.

Além disso, quando da abordagem pessoal no acusado e no terceiro Danilo, com ambos foi encontrada porção de maconha, tendo Danilo afirmado que foi o denunciado quem lhe forneceu o entorpecente.

Sendo que ele próprio confessou aos policiais que estaria praticando tráfico de entorpecentes na região.

Ora, o indivíduo que é flagrado na posse de substâncias entorpecentes, substâncias essas que teria confessado que eram destinadas ao tráfico. Tais circunstâncias permitem supor, com uma certa profundidade, de que há suspeita de que o acusado se vale da residência para prática do ilícito.

Tal situação, por si só, já dispensaria a prévia autorização judicial para ingresso no domicílio.

Também não há qualquer sinal de arrombamento, testemunhas de ingresso forçado, nada. Apenas a palavra do réu negando o consentimento, indo de choque a todos os demais elementos dos autos, especialmente o harmonioso e incontestado depoimento das testemunhas.

Dessa forma, observo, portanto, que a conduta está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Este é, inclusive, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

"Habeas corpus" - Tráfico de drogas - Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio - Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente - Não acolhimento - Ausência de constrangimento ilegal - Inteligência do art. 5º, XI, da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" - Tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" - Crime permanente - Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) - Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente - Precedentes - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057567-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

Assim posto, resta afastada qualquer nulidade da obtenção da prova..

O feito encontra-se em ordem. Não há outras preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da lei 11.343/06)

A materialidade delitiva resultou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 03/10), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 20/23), Fotografias (fls. 41/52), Laudo Pericial de Constatação Provisória de Entorpecentes (fls. 131/132), Final oferecido pelo Delegado de Polícia (fls. 119/120), Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico (fls. 197/199), bem como pela prova oral colhida.

A autoria resta igualmente demonstrado, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem qualquer sombra de dúvida, a autoria delitiva do réu.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Valdison de Oliveira Souza declarou em juízo que estava em patrulhamento de rotina pelo bairro do Reino. Fizeram a abordagem do denunciado, juntamente com um casal. Com a pessoa de Danilo foi encontrada uma porção de maconha, a qual ele afirmou que havia acabado de adquirir do denunciado Kaiky, que reside próximo ao local da abordagem, cerca de trinta metros. Disse, ainda, que havia diversas denúncias a respeito de tráfico com o nome de Eduardo Kaiky. Se dirigiram ao endereço residência do denunciado, onde funciona, ou funcionava, uma oficina mecânica de veículos. Chegando próximo ao endereço, o irmão do denunciado avistou a viatura policial e correu para o interior da residência, o que motivou o acompanhamento dele até o local. Inclusive, o irmão teve que ser contido, pois estava bastante alterada. Nesse momento, a avó do Kaicky apareceu no local e disse que Kaicky mora com ela e autorizou o ingresso e vistoria no endereço. De pronto, a equipe já conseguiu localizar, na varanda do imóvel, uma mochila que continha porções de maconha embaladas a vácuo. A própria avó indicou o quarto do Kaiky, onde foram encontradas mais porções de cocaína, semelhantes aquelas que foram apreendidas com a pessoa de Danilo. Ainda foram encontradas munições, 3 delas intactas e 4 deflagradas. No veículo Renault Clio, de propriedade

do denunciado, foi encontrado um tijolo de maconha, mais outros nove pedaços de maconha fracionados e também uma certa quantia em dinheiro. Em outro veículo, que era uma carcaça, na verdade, foram encontradas outras porções de drogas. Após essa apreensão, Eduardo Kaicky confessou a prática do tráfico, sustentando que a droga era inteiramente sua, isentando seus parentes de qualquer responsabilidade. A testemunha arrolada pelo Ministério Público Jhon Natan Taborda Dechico, ouvido na qualidade de informante, tendo em vista ser irmão do réu, narrou em juízo que: Estava passeando com seu cachorro quando foi abordado pelos policiais. Negou que sua avó teria permitido o ingresso dos policiais na residência. Negou que tenha falado na delegacia que o ingressos dos policiais foi permitido. Disse que sua avó estava impedindo o acesso na casa dela, e os policiais já estavam lá dentro no interior do imóvel. Disse que eles entraram sem permissão. Relatou que chegou a ser agredido pelos policiais, apenas tentando se defender. Atestou a boa conduta do réu.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Danilo Santos de Freitas, ouvido, narrou em juízo que:

Disse que estava na praça do Reino, e foi abordado pela polícia. Confirma que com ele foi encontrada uma porção de maconha, que era para seu próprio consumo. Disse que apenas deu uns tragos com ele, e o que sobrou desse cigarro ele levou para casa. Foi um cigarro do acusado Danilo, que estavam fumando juntos e ele levou o restante. Falou que somente estavam fumando juntos, foi somente um baseado pequeno. Sustentou que os policiais o pressionaram para afirmar que as drogas foram fornecidas pela Kaicky. Foi pressionado para que desbloqueasse o celular. No momento da abordagem, o único entorpecente encontrado com ele foi um pequeno pedaço de maconha.

A testemunha arrolada pela defesa Ellen Sophia, ouvida na qualidade de informante do juízo por ser irmã do acusado, narrou em juízo que:

Declarou que viu seu irmão sendo abordado pela polícia e foi indagar o que estava ocorrendo. Nesse momento, os policiais estavam descendo com a namorada do Kaicky. Os policiais a empurraram, mandando ela entrar em casa. Ela se negou a obedecer. Disse que foi empurrada pelos policiais para que entrar no imóvel, até chegar na entrada da casa. Não estava deixando os policiais entrarem na casa, não autorizando eles a entrar. Foi empurrada pelos policiais. Nesse momento, seu irmão mais velho Jhon chegou com o cachorro, foi quando começou a confusão. Ela e seu irmão John foram algemados, aguardando no lado de fora da casa. Foi machucada pelos policiais. No momento da confusão, sua avó chegou ao local. Mas quando ela chegou, os policiais já estavam dentro do terreno, onde eles entraram sem permissão. No local existem várias construções independentes, inclusive uma oficina de carros do seu avó. Disse que Kaicky morava com sua mãe e ela, sendo que sua mãe não estava em casa no momento. O denunciado ficou na viatura e não acompanhou as buscas. O terreno todo é do seu avó e de sua avó, mas a casa onde encontrados os entorpecentes e munições pertence a sua mãe.

A testemunha arrolada pela defesa Ivone Taborda, ouvida na qualidade de informante do juízo por ser avó do acusado, narrou em juízo que:

No dia dos fatos, sua nora foi até a casa dela, dizendo que Eduardo Kaicky estava sendo abordado pela polícia no campo do Reino. Entrou para sua casa para tomar um remédio. Nesse momento, seu marido informou que estava tendo uma confusão na casa da filha dela, solicitando que ela fosse ver o que era. Foi até o local para ver o que acontecia. Viu a confusão entre os policiais com o John Natan e a Sophia. Quando chegou ao local os policiais já estavam na casa de sua filha. Os policiais realizaram a vistoria na casa do Kaicky. A situação se acalmou. Gravou um áudio autorizando a busca nos cômodos do denunciado. Acompanhou as buscas e que nos carros abandonados perto da cachoeira, encontraram entorpecentes. E também encontraram entorpecentes no carro do denunciado. Que não tinha condições de se opor à busca, mas autorizou a busca. Disse que não teve opção a não ser autorizar a busca, pela situação e também por estar enferma. Que é uma pessoa passiva. Que não tinha como se opor à busca policial. Que o terreno lhe pertence e cedeu partes deles para familiares. Que aluga outras residências no local.

A testemunha arrolada pela defesa Giuliane Taborda de Brito, ouvida na qualidade de

informante do juízo por ser mãe do acusado, narrou em juízo que:

No dia dos fatos não estava em casa, tinha ido em Ubatuba resolver uma situação. Reside com Eduardo Caicky e Sophia. No mesmo terreno, são três casas separadas, uma de sua mãe, uma onde mora com Kaicky e Sophia e outro onde mora seu filho John. O terreno inteiro pertence a sua genitora, mas a casa onde ela mora é dela. Declarou não saber da existência dos entorpecentes, atestando a boa conduta de Kaicky. Interrogado, o réu EDUARDO KAICKY GARCIA disse que não desejava se manifestar sobre os fatos.

Com relação ao tráfico, calha ressaltar, por oportuno, que os delitos previstos nos artigos 33 e 28 da Lei nº 11.343/06 restam consumados sempre que a conduta fática do agente se ajusta com perfeição a um dos comportamentos delineados pelos dois dispositivos legais.

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - rel. ADOLPHINO RIBEIRO - RDTJRJ 20/310).

No §2º, artigo 28, da Lei de Tóxicos, está disposto que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Analizados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada no caso em questão destinava-se ao tráfico, mormente pela grande diversidade e quantidade encontrada, quantidade esta incompatível com o mero usuário.

Cabe citar que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º11.343/2006) em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e 01/07/2016)

TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido Recurso improvido

(TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01/04/2015).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser

inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do representado logo antes ou no momento da apreensão, a existência de outros elementos referentes à venda, etc.

Nesse sentido:

"A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções da droga capturada, somadas à apreensão de apetrechos geralmente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, bem como de certa quantia em dinheiro, são fatores que indicam envolvimento maior com a traficância, autorizando à preventiva." (HC 323.748/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, REPDJ e 05/10/2015, DJ e 28/09/2015).

A testemunha policial, quando ouvida em juízo, afirmou ter encontrado na residência do acusado primeiramente na varanda do imóvel, uma mochila contendo 288 (duzentos e oitenta e oito) porções de cocaína embaladas à vácuo. Além disso, o policial ainda asseverou que no quarto do denunciado, foram encontradas outras 11 (onze) porções de maconha, idênticas aquela encontrada com a pessoa de Danilo, abordado junto com Kaicky com entorpecentes. Ainda no quarto do denunciado foram encontrados petrechos comumente utilizados para o tráfico tais como balanças de precisão e embalagem de alumínio. Também foram encontradas outras substâncias entorpecentes em dois veículos que estava parados no imóvel, os quais se ligam diretamente ao denunciado.

O depoimento policial está em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, devendo ser acolhidos não os desqualificando o fato das testemunhas serem policiais, não havendo demonstração de que, sem qualquer motivo aparente e relevante, teriam os milicianos interesse em prejudicar o acusado. Ademais em sendo agentes do Estado, certamente gozam de presunção de legitimidade de seus atos, não havendo o mínimo indício que teriam agido dolosamente, inexistindo qualquer contradição ou modificação em ambos os depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial como em Juízo. Assim, os pontos essenciais da prisão e da apreensão da droga foram confirmados pelo policial militar ouvido no contraditório judicial, inexistindo pontos conflitantes que servissem para afastar um decreto condenatório. Assim, prevalece a versão policial eis que imparcial.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 76.608-0 - STF - DJU 11.04.97). "ENTORPECENTES - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido" (TJSP - Ap. 264795-3 - 6ª Câmara Criminal - Rel. Des. Debatin Cardoso).

"ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Portanto, nada há nos autos para infirmar a voz dos agentes públicos. Assim, diante da quantidade de entorpecentes encontradas na ocasião, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, são fatores que reunidos permitem obter a certeza que

trazia as drogas para os fins de tráfico, sendo incabível a desclassificação do delito. Comprovada a materialidade, a finalidade da droga e a autoria, procedente o pedido contido na exordial. As provas produzidas na fase inquisitorial foram amplamente corroboradas no decorrer da instrução no contraditório judicial, de forma que a procedência é de rigor. Dessa forma, mister se faz a condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Posse ilegal de arma de fogo-art. 12 da lei 10.826/03).

A corrente doutrinária majoritária classifica o crime a partir de três elementos (teoria tripartite), quais sejam: fato típico, ilicitude e culpabilidade.

O fato típico é o fato humano que se enquadra com perfeição aos elementos descritos pelo tipo penal.

A doutrina aponta como sendo quatro os requisitos do fato típico: conduta, resultado naturalístico, relação de causalidade (nexo causal) e tipicidade.

Dentro os elementos que compõem o fato típico, se encontra a tipicidade (strictu sensu). Esta pode ser dividida em formal e material.

Tipicidade formal é o juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente e a norma penal.

De seu turno, tipicidade material é a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado.

No caso dos autos, anoto que, embora comprovada a tipicidade formal da conduta (mera subsunção do fato à norma), entendo ausente a tipicidade na vertente material.

Isto porque, conforme se observa do auto de exibição e apreensão de fl. 20/23, com o denunciado foi apreendido tão somente três cartuchos íntegros de calibre .380, desacompanhado de qualquer arma de fogo capaz de efetivar o disparo de tal projétil.

Em tal caso, a situação se amolda com perfeição à aplicação do princípio da insignificância.

O princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, justamente pela falta de sua vertente material.

Segundo o Des. do TJSP Carlos Vico Manãs "o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, de sua efetiva lesividade ao bem jurídico penalmente tutelado".

Corroborando este entendimento, segue recente julgado do E. Superior Tribunal de Justiça com aplicação do princípio da insignificância em caso análogo ao presente: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES EM CONCURSO MATERIAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens.

- Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ.

- A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos oito cartuchos calibre .38,

desacompanhados de arma de fogo, ainda que no contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto trata-se de paciente primário e de bons antecedentes, cuja dedicação às atividades criminosas - a qual justificou a negativa de incidência do tráfico privilegiado na fração máxima legal -, somente foi reconhecida, em virtude de ele possuir somente uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude (Proc. n. 0002891-76.2014.8.26.0495), razão pela qual lhe foi aplicada uma medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, cuja execução foi julgada extinta por sentença proferida em 15/10/2015 (e-STJ, fl. 149).

- Nesses termos, entendo ser cabível a flexibilização do entendimento consolidado nesta Corte de Justiça para o reconhecimento do princípio da insignificância, ante as particularidades do caso concreto e das condições pessoais do paciente.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 534.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

Assim sendo, de rigor a absolvição do acusado em relação ao crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, bem como do art. 42, da lei 11.343, observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Não há elementos suficientes para valorar negativamente sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais à espécie de delito. Contudo, na esteira do art. 42, da lei 11.343/06, merece ser valorada negativamente a circunstância do fato, consistente na grande quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado. Conforme se observa do auto de constatação provisória (fls. 25/26), em poder do acusado foram apreendidas 792 (setecentos e noventa e duas) porções de cocaína, totalizando o peso bruto de 616 gramas, além de 2 (dois) tijolos de maconha, totalizando 1.564 kg da droga e outras 20 porções fracionadas de maconha, com peso bruto de 783,9 gramas. Trata-se de vultuosa quantidade de entorpecente, ainda mais considerando as peculiaridades locais. Dessa forma, majoro as penas-base acima dos patamares mínimos legais, fixando-as em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, forçoso que se reconheça que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, incidindo a atenuante da menoridade relativa, diminuindo as penas para os seus mínimos legais, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a prova dos autos é suficiente para concluir, seguramente, que ele se dedica à prática reiterada do tráfico ilícito de drogas. É certo que a Nova Lei de Drogas aperfeiçoou a sanção penal ao operar a distinção entre meros mercadores ocasionais, também merecedores de atenção do Estado, dos comerciantes de droga mais estruturados, verdadeiros empresários do tráfico. Distinção reclamada há muito tempo pelos aplicadores do Direito, tem por consequência a menor reprovabilidade da conduta do traficante ocasional e sua pena encontra fundamento e limite com a redução a integrar o tipo penal para os que apresentem as condições subjetivas típicas daqueles que não tenham estruturado envolvimento com o tráfico de drogas.

No presente caso, entendo não ser cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, justamente por considerar as circunstâncias do caso concreto, especial a variedade (cocaína e maconha) e a grande quantidade de entorpecente apreendida em poder do sentenciado (peso líquido de 441,7 gramas de cocaína e 2.255,7kg de maconha), conforme laudo de constatação preliminar de fls. 130/131. Para se ter uma ideia, um cigarro de maconha possui em média de 0,5g a 1,5g da droga. Ou seja, a quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado serviria para divisão em cerca 2 (dois) mil cigarros. No caso da cocaína. Não bastasse esse montante elevadíssimo de entorpecentes apreendidos, ainda em poder do acusado foram encontrados petrechos que são comumente utilizados por traficantes habituais, tais como balanças de precisão, rolos de papel filme e papel alumínio, celulares diversos, caderno com anotações de contabilidade do tráfico.

Tais circunstância trazem o juízo de certeza que o sentenciado, a despeito de sua primariedade, faz do tráfico de drogas seu meio de vida, se dedicando a atividades criminosas de forma habitual.

Os requisitos previstos no art. 33, §4º, quais sejam primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa são CUMULATIVOS, de modo que para o acusado fazer jus a tal causa de diminuição de pena, devem estar presente todos os requisitos, o que não é o caso do sentenciado, uma vez que se dedica a atividades criminosas.

A respeito da possibilidade de a quantidade e variedade de drogas ser avaliada para aumentar a pena-base e, também, afastar o tráfico privilegiado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIPO POR VIOLADO, QUANTO A UMA DAS TESES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR.

POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NOS DOIS DELITOS, PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE, TAMBÉM NOS DOIS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INFRAÇÕES DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...) 4. É permitido valorar a natureza e a quantidade da droga negativamente na primeira-fase da dosimetria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que isto configure bis in idem. (...) 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido" (AgRg no REsp 1675656/RS 5ª Turma do STJ Rel. Min. Ribeiro Dantas j. 09/3/2021).

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADA PELO TRIBUNAL LOCAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.

IDONEIDADE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE AO PACIENTE LEANDRO. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA INSTÂNCIA A QUO. ALTERAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.

CONVICÇÃO DA CORTE LOCAL QUE O PACIENTE EXERCIA A TRAFICÂNCIA DE FORMA HABITUAL.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VIII - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade, na diversidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 48 g de cocaína; 35,5 g de crack; e 155 g de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que os pacientes se dedicavam, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficantes ocasionais. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 627596/SP 5ª Turma do STJ Rel. Min. Felix Fischer j. 02/3/2021).

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, torno-as de definitiva nesse montante.

Consoante a pena aplicada, sendo o réu primário, fixo o regime SEMIABERTO, para início de cumprimento de pena, consoante art. 33, §2º, do Código Penal.

O valor do dia multa vai no mínimo legal.

Pelo montante de pena aplicada, inviável a substituição da pena e a concessão de sursis, na forma dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado EDUARDO KAICKY GARCIA, por ter praticado fato tipificado no art. artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no patamar mínimo legal, com regime inicial SEMIABERTO para cumprimento de pena.

Cumprе salientar que os tribunais superiores possuem firme entendimento de que nas hipóteses em que fixado regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, incabível se mostra a manutenção da custódia cautelar. E é exatamente o caso dos autos. A pena fixada ao acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO de modo que se mostra incompatível a manutenção da custódia cautelar.

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.

(HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017)

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 316 e 319 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de EDUARDO KAICKY GARCIA, e, em substituição, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares diversas:

(a) comparecimento bimestral em Juízo, para comprovar e justificar as suas atividades (CPP, art. 319, I);

(b) não frequentar bares e similares, nem ingerir bebida alcoólica, ou fazer uso de substâncias entorpecentes (CPP, art. 319, inciso II);

(c) não se ausentar da Comarca onde reside sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, IV), por período superior a 08 dias; bem como proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo; e

(d) recolhimento à sua residência e dentro dela permanecendo em tempo integral todos os dias das 22h00min às 06h00min; (CPP, art. 319, V).

Cientifique-o de que o não cumprimento de qualquer condição imposta poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4.º e 312, parágrafo único, ambos do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição e incineração das drogas apreendidas, na forma da referida lei.

Nos termos do art. 509 das NSCGJ, providencia a zelosa serventia o cadastro das munições apreendidas no sistema informatizado oficial-SAJ, certificando nos autos.

Outrossim, a Lei nº 10.826/2003, em seu artigo 25, "caput", determina o encaminhamento das munições apreendidas ao Comando do Exército para destruição, conforme segue descrito: "Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)". Desta forma, considerando a presença de laudo pericial acostado aos autos, AUTORIZO desde já o encaminhamento ao Comando das Forças Armadas para DESTRUIÇÃO ou DOAÇÃO. Oficie-se.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos nestes autos em favor da União, nos termos do art. 63, I, da lei 11.343/06.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado:

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art.

336, caput, do Código de Processo Penal , o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);
Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;
Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;
Ofícios de praxe;
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Ilhabela, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA